

114年公務人員特種考試司法官考試第二試
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試
法律專業科目評分要點與閱卷委員的話

科目：智慧財產法

第一題

【總題說明】

由於發明專利侵權之均等侵害評價在現今專利相關訴訟有其重要性，本題之出題意旨在於測驗應考者對於專利侵權均等論相關法理基礎以及適用之理解程度。另外，在專利侵權訴訟中，「申請歷史禁反言」原則以及「先前技術阻卻」原則，亦為當事人針對均等侵害所提出常見之抗辯，應考人在專利法的學習上亦有瞭解之必要。因此，本題共分為三個子題，第(一)子題為均等論之解釋，第(二)及第(三)子題分別為「申請歷史禁反言」原則與「先前技術阻卻」原則於專利侵權訴訟中之應用。

【評分要點】

第(一)子題

本子題關於均等論之作答，應包括均等論之目的及評價方法。關於均等論之目的，專利權之侵害就法理以及法院實務而言，可分為文義侵害與均等侵害。前者嚴格採取全要件原則，一旦侵權物或相關製程之各要件，經所屬技術領域具有通常知識者之解釋，得以讀入申請專利範圍之各要件時，即構成專利權之文義侵害。均等侵害則是在衡平上補充文義侵害相關評價之不足，避免侵害者於不法實施申請專利範圍時，刻意選就部分發明評價上較不重要之要件加以差異化，以規避文義侵害。此部分，在評閱時，依答題內容，酌以0至5分之評分。

在評價方法方面，大致上有二種評價方法。第一種為實質差異法，舉凡侵權物或製程之相關要件或步驟為規避文義侵害評價所為之調整，若不具實質評價之重要性，仍構成均等侵害之評價（最高法院103年度台上字第1843號民事判決參照）。第二種為三部測試法，當侵權物或製程所調整之要件或步驟，於所對應之申請專利範圍之要件或步驟，是在實質相同之功能下，以實質相同之手段而達致實質相同之結果，亦構成均等侵害（最高法院110年度台上字第1791號民事判決參照）。此部分，應考人若能選擇其中一種評價法加以論述，在評閱時，

依答題內容，酌以 0 至 5 分之評分。

第(二)子題

發明專利權範圍之公示，係以全要件原則為中心。專利 P 之請求項 C 由 C0、C1 及 C2 三要件所構成，後因保全專利要件（進步性要件）之成就，於專利申請中將 C0 要件修正為 C3 要件，在專利申請公開下導致權利公示範圍之改變，為保障交易安全與權利範圍正確信賴，在法理上形成均等侵害評價之限制，我國法院實務稱為「申請歷史禁反言」。一旦專利申請人為滿足專利要件之目的，透過修正程序對於特定請求項之要件加以置換或變更時，本於此置換或變更之結果，未來主張專利權侵害之均等論相關權利，除有例外之情形，原則上將依「禁反言」之法理加以排除，令專利權人僅能就修正後相關請求項之文義，主張專利文義侵害。（智慧財產法院 106 年民專上字第 28 號民事判決參照）

本子題甲之專利修正申請乃是為克服進步性要件之目的，將 C0 要件限縮修正為 C3 要件，而 C3 要件為 C0 要件之下位要件，依「申請歷史禁反言」法理，甲對於專利 P 之請求項 C 僅能就 C1、C2 及 C3 等三要件主張文義侵害，亦即在權利範圍主張上，因禁反言而等同放棄納入 C0 要件下位之其他所有要件，包括本題所提及之 A 要件，故不得對 F 之製造販賣主張均等侵害。

本子題評分可分為二部分。第一部分為「申請歷史禁反言」之定義，在評閱時，依答題內容，酌以 0 至 5 分之評分。第二部分為該原則於本子題相關事實之解釋適用，依答題內容，酌以 0 至 10 分之評分。

第(三)子題

先前技術阻卻為均等侵害之例外，其主要目的，在於避免專利權人藉由均等侵害之主張而將先前技術納入發明專利權範圍，而破壞了先前技術於申請日前存在之市場交易秩序，同時，如此結果亦與專利法鼓勵創新之立法意旨相違背。

本子題專利 P 有一先前技術 PR，而依專利 P 申請日之發明所屬技術領域具有通常知識者之解釋，F 物之要件 C1 與先前技術 PR 要件 X 等同，F 物之要件 C2 與要件 Y 等同，而 F 物之 A 要件雖與先前技術 PR 之 Z 要件在發明要件判斷上相區別，但為 Z 要件之替代要件，A 要件僅為 Z 要件之簡易置換，為產業所習知，亦即 A 要件得由 Z 要件之解釋而直接無歧異推之。因此，基於先前技術之阻卻，甲不得就 F 物之販賣主張均等侵害。至於法院實務上如何適用，智慧財產及商業法院曾於 112 年度民專上字第 8 號民事判決中強調：「判斷是否適用先前技術

阻卻，應於判斷系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵是否為均等之同時一併考量。又判斷是否適用均等論時，若被控侵權人主張先前技術阻卻，且經判斷被控侵權對象落入專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同，或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識的簡單組合，則適用先前技術阻卻，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。」可資參照。

本子題評分可分為二部分。第一部分為「先前技術阻卻」之解釋以及測試方法，在評閱時，依答題內容，酌以 0 至 5 分之評分。第二部分為該原則於本子題相關事實之解釋適用，依答題內容，酌以 0 至 10 分之評分。

【閱卷委員的話】

第(一)子題

本題題意明確，詢問考生均等論之意義。完整作答除應闡釋均等論涵義外，亦應論及適用均等論之判斷方式。本子題考生作答情形，觀察如下：

1. 有掌握均等論概念與判斷者：

作答內容有提到專利侵害判斷分為文義侵害與均等侵害，並進一步說明均等論之涵義。繼而就均等侵害判斷部分，有部分考生能具體寫出三部測試法，亦即以實質相同之方式、發揮實質相同之功能，並得到實質相同結果者，可得高分。有部分考生對於均等論之概念論述正確，但並未具體提及「三部測試法」之用語者，閱卷時仍會由考生作答實質內容予以判斷給分，倘考生作答內容係在論述以相同的方式、功能，得到相同結果之意涵者，亦能獲得分數。

2. 沒有掌握均等論概念而隨意作答者：

部分考生之作答內容顯然對均等論並不了解，作答時有從均等論的字義上隨意解釋，例如泛泛回答均等論係指發明專利每一個請求項均可受到保護；或是誤認均等論乃係適用於相同發明有前後專利申請時，用以駁回後申請案之判斷標準。亦有考生誤認均等論之判斷，是以系爭專利權請求項與先前技術進行比對。凡此作答內容，均非正確。

第(二)子題

本子題主要在測驗考生就「申請歷史禁反言」概念之理解，本子題考生作答情形，觀察如下：

1. 有掌握到申請歷史禁反言概念與意涵者：

有部分考生能具體寫出申請歷史禁反言（或者是類似用語），且能正確說明其概念涵義，可得高分。考生雖未具體敘及申請歷史禁反言或類似用語，閱卷時會依作答內容予以評分，部分考生之作答內容，雖未出現申請歷史禁反言用語，惟其作答內容若係在討論本題甲在申請過程當中基於克服進步性要件之目的，而將 C0 要件限縮修正為 C3 要件，則甲自然就不可以再透過均等論要擴張其專利範圍，蓋因就甲自己限縮請求項，表示放棄納入 C0 要件下位之其他要件等內涵者，亦可呈現考生之論述為申請歷史禁反言概念之分析，閱卷時將依論述完整性與正確度給予分數。

2. 偏離本題爭議而作答者：

部分考生作答內容完全沒有針對甲在申請過程中限縮修正的事實，反而是針對 A 及 C3 要件是否屬於 C0 要件之下位要件而予以討論，最後並適用均等論而提出結論。亦有部分考生作答內容聚焦於分析甲之專利是否仍具進步性，然此非本題測驗之主要爭議。

另本題的主體有甲、乙，有不少考生作答內容將甲、乙主體錯置之情形。

第(三)子題

本子題主要在測驗考生就「先前技術阻卻」概念之理解，本子題考生作答情形，觀察如下：

1. 掌握先前技術阻卻概念並正確涵攝本題事實者：

部分考生作答內容，正確寫明先前技術阻卻（或是先前技術抗辯等類似用語），且作答內容亦具體涵攝本題，分析基於先前技術阻卻，甲何以不得就 F 物的販賣主張均等侵權等事實者，可得高分。

2. 未提及先前技術阻卻用語者：

有部分考生作答並未提及先前技術阻卻於本子題之適用，閱卷時會依作答內容是否能呈現出考生有在討論此概念而酌給分數。例如：有部分考生雖未寫明先前技術阻卻之用語，然其作答聚焦於分析先前技術 PR 與 Z 要件，進而討論基於已經存在之先前技術 PR 所完成之 F 物是否構成對甲專利之侵害等。

3. 有部分考生作答著眼於是否得基於題意事實而對甲之發明專利提起舉發，以是否不具進步性或新穎性要件而為分析，然此非本子題所涉爭議。另本子題作答內容中，亦有出現考生將甲、乙主體錯置而為作答之情形。

第二題

【總題說明】

本題主要是測驗應考者對於著作財產權受侵害要件之正確理解，以及於個案上之解釋應用。由於我國著作權法對於著作財產權受侵害要件判斷標準及方法，並未詳加規定，因此，依歷來實務見解及最高法院判決意旨於認定有無侵害著作財產權之事實時，當審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害之要件，即接觸及實質相似（或稱實質近似）予以調查，其中所謂接觸，分為直接接觸與間接接觸，所謂實質相似，兼指量的相似與質的相似（107 年度台上字第 1783 號、108 年度台上字第 1315 號民事判決參照）。法院於判斷有無侵害著作財產權，首應依著作權法第 5 條第 1 項第 1 款、第 9 條規定，定性 A 小說是否應受著作權法之保護及其著作權之種類（語文著作）。然後應考者應依本題設定之事實及證據，按上開侵害之要件論述 A 小說語文著作是否受侵害，並就原創性、重製之定義及思想表達合併原則於本題之應用為說明。如應考者於第（一）子題論述著作權法第 65 條第 2 項第 3 款規定，雖作答方向不正確或理解有誤，惟會依論述內容酌給分數，於第（二）子題敘及乙之 B 小說不符合合理使用之情形，亦會依論述內容酌予加分。

【評分要點】

第（一）子題

法院於認定有無侵害著作權之事實時，當審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害之要件，即接觸及實質相似予以調查。其中所謂接觸，分為直接接觸與間接接觸，所謂實質相似，兼指量的相似與質的相似。此部分之評分，原則上應考者若作答內容敘及「接觸及實質相似」，並就「接觸」及「實質相似」進一步敘述其種類，即可獲得相當分數。

又判斷語文著作有無抄襲情形時，宜就重製行為之態樣，就其利用之質量，按社會通念及客觀標準分別考量之。於第（一）子題敘及此觀念者，酌予給分。

應考者如能就上開侵害要件，進一步依實務見解或引用最高法院上開判決要旨，敘及間接接觸，係指依社會通常情況，行為人具有合理機會接觸或可能見聞著作物而言。如著作物已行銷於市面，行為人可輕易取得，或著作物有相當程度之廣告或知名度，均屬之。所謂實質相似，應就爭執抄襲部分著作之文字及非文字部分加以比對分析，如認二者相似程度頗高或屬著作之主要成分，縱使僅占

著作之小部分，亦構成實質相似。就第(一)子題之評分會依論述之詳盡程度，可獲得較高分數。

應考者若於第(一)子題引用著作權法第 65 條第 2 項規定合理使用為侵害要件之作答，雖作答方向不完全正確，但因為此條項第 3 款規定所稱「所利用之質量及其在整個著作所占之比例」，係指所利用部分在新著作中及被利用著作中，兩相衡量，就整體觀察其質量各所占比例」，會依應考者之論述內容酌予給分。

第(二)子題

舉凡著作財產權侵害事件，法院於審理時，首先會就原告主張之著作，依著作權法第 5 條第 1 項第 1 款、第 9 條規定，定性其著作之種類，再就其是否為應受著作權法保護之著作為確認。本件 A 小說為甲以文字表達作者其思想與感情之創作，具有原創性，亦非著作權法第 9 條各款所定不得為著作權之標的，即應受著作權法之保護，而屬著作權法第 5 條第 1 項第 1 款所稱之語文著作。此部分之評分，原則是依應考者的作答內容給予相當之分數。

為判斷乙之 B 小說是否抄襲甲之 A 小說，應就 B 小說之內容，就乙利用 A 小說之質量，按社會通念及客觀標準為考量。應就本題給予之事實及證據，依重製之定義（著作權法第 3 條第 1 項第 5 款前段規定係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作），搭配第(一)子題之侵害要件為剖析，得到「依 B 小說利用之質與量，按社會通念及客觀標準審查，構成實質近似，且乙有接觸 A 小說之事實，故乙構甲 A 小說重製權之侵害，甲有關乙侵害著作權之主張，為有理由。」之結論者，亦可獲得相當之分數。

承上，若就關於質的相似部分，論述經專家檢視比對 A 小說與 B 小說之內容，認定兩小說之人物塑造、角色設定、故事情節及寫作表達方式極為近似，以上皆為小說創作之重要成分，故 B 小說與 A 小說構成質的相似。關於量的相似部分，兩小說文字重疊率高達 85%，更有相同的中文錯別字共 12 字及英文拼音錯誤共 7 字，則 B 小說於乙所利用之整體著作 A 小說，所占之比例極高，構成量的相似。因此，乙之 B 小說與甲之 A 小說確係實質近似。並進一步論述，客觀上，乙之 B 小說與甲之 A 小說，在質、量上已構成實質近似，且甲之 A 小說出版後行銷於市面，乙可輕易取得，且 A 小說榮登小說排行榜冠軍長達 1 年，依社會通常情況，乙具有合理機會接觸或可能見聞 A 小說（間接接觸）。而兩小說文字重疊率高達 85%，近似程度極高，B 小說更有相同的中文錯別字共 12 字及英文拼音錯誤共 7 字，足見乙確曾直接接觸過 A 小說。依應考者論述內容將可得較

高之評分。

實務上法院就被告之辯解必須給予採納或駁斥之理由，否則為判決理由不備，本件應考者如為甲主張乙所謂奇幻小說原本就有起承轉合，往往有雷同之錯覺，但依思想與表達合併原則，B小說並未侵害A小說著作權之辯解，以所謂思想與表達合併原則，係指思想與概念如僅有一種或有限之表達方式，此時因其他著作人無他種方式，或僅可以極有限方式表達該思想，如著作權法限制該等有限表達方式之使用，將使思想為原著作人所壟斷，該有限之表達即因與思想、概念合併而非著作權保護之標的。奇幻小說固充滿幻想要素，以奇幻與想像為其特色，惟乙可以選擇不同之表達方式進行人物設定與劇情安排，如此即可彰顯B小說所為表達之原創性，其表達方式並非唯一或極少數，並非有限性表達之情形，無思想與表達合併原則之適用為理由予以論駁，依應考者論述精確程度酌予加分。但若應考者未具體論述即遽下結論，則難以取得高分。

如應考人敘及乙之B小說不符合合理使用之情形，會依論述內容酌予給分。

應考者就第(二)子題之結論為不侵權者，其結論錯誤，仍會依論述內容酌予給分，但分數會較低。

【閱卷委員的話】

本題旨在測驗應考者對於著作財產權受侵害之判斷要件是否能作出正確理解，以及具體個案中應如何分析權利人主張侵害著作財產權之事實及證據(如題目所指A小說為受著作權法保護之何種著作、抄襲A小說侵害之權利為何、專家檢視兩小說的表達方式極為近似、文字重疊率、錯別字及拼音錯誤相同等情應如何評價)，是否有理？以及侵害人所提出之不侵權辯解理由(依題意為無抄襲之獨立創作、思想表達合併原則)是否合理？均應就題目所列雙方爭執事項所呈現之事實及證據予以逐一論述或駁斥是否可採，並得出正確結論，始能獲致高分。

第(一)子題

本題答題重點應著墨於判斷著作受侵害之要件上，由於我國著作權法對於著作財產權受侵害應從何方面進行判斷並無明文，依歷來實務見解及最高法院判決意旨，均就創作人有無「接觸」原著作以及兩著作是否構成「實質相似」(或稱實質近似)，分別予以論斷，因此，本題自應就「接觸」及「實質相似」的要

件及內涵作進一步闡述。然為數不少之應考人似未能正確理解此子題之題旨，不僅完全未提到上開要件（然有少數應考人將「接觸」及「實質相似」之判斷要件寫在第(二)子題），甚而偏重在論述著作財產權之成立要件，或侵害著作財產權之行為態樣及請求權依據，或以未經授權或是否構成合理使用之要件作為判斷是否侵害著作權，均已偏離題旨，因此普遍上評分自然較低，實屬可惜。

第(二)子題

本題所列雙方爭執事項已如前述，故論述重點依序應放在受保護著作之定性、乙侵害甲著作財產權之種類，以及就題示「兩小說均為奇幻小說之內容、甲小說榮登排行榜冠軍長達1年、兩小說之人物塑造、角色設定、故事情節及寫作表達方式極為相似、兩小說文字重疊率高達85%，更有相同的中文錯別字共12字及英文拼音錯誤共7字」等重要事證，依「接觸」及「實質相似」要件進行充分分析及論述，即可獲致構成侵權之正確結論；另需就乙所提出之無抄襲辯解（即獨立創作、思想表達合併原則），認為不成立之理由進行論述。多數應考者對於此部分論述均能掌握重點，並正確指出構成侵權之結論，但在論述上仍欠缺完整性或有部分錯誤，常見的遺漏為未提及甲小說之著作性質及是否為著作權法保護之著作，常見錯誤為著作權人受侵害者為重製權，然少數人混淆重製權與改作權之基本觀念，誤以為乙之抄襲行為侵害改作權，或僅以乙是否構成合理使用之要件進行侵權判斷。至於有少數應考者對於重要侵權事證並未具體分析論述，即遽下侵權之結論，更有極少數人在依重要事證分析論述後反而作出不侵權之結論，核與本題所列重要事證不符，分數自然偏低。

另應注意者，由於題目中乙對甲並未提及合理使用之抗辯，因此不應以大篇幅論述乙不構成合理使用，故成立對於甲之著作權侵害，而遺漏就前揭重要事證之侵權分析，否則無法獲得該有的分數。但如應考者在完整論述侵權要件之後，兼併敘及乙之B小說不符合合理使用之要件並為適當論述，則為酌予加分之事由。

第三題

【總題說明】

以商標包含「地名」為例，測驗應考人對商標識別性及侵害商標權損害賠償之了解及應用程度。

【評分要點】

第(一)子題--包含地名「甲」字之商標

1. 本題應論述「甲」字表示地理名稱、產地部分，是否對商標權範圍產生疑義說明理由。

商標法第 29 條規定：「(第 1 項) 商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。……(第 2 項) 有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。(第 3 項) 商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」又第 35 條第 1 項規定：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」

商標之主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法指示及區別商品或服務之來源，而不具有識別性，即不具商標功能，自不得核准註冊。地理名稱使用於商品或服務，給予消費者的印象，通常只是商品或服務與該地理區域有所關聯之說明，消費者容易產生地名與來源地之聯想，而將之視為產地說明，應屬地理名稱之描述性使用，不具先天識別性。

A 公司之「X」商標所使用之地理名稱「甲」是否產生商品說明之聯想，以我國消費者之認知為準。甲地區水質清淨甘甜味美，全臺聞名，商標權人 A 公司之「X」商標圖樣之下方有地名「甲」字，指定使用於「茶飲料、果汁、礦泉水」商品，有說明商品之產地、地理來源的意涵，「甲」字部分不具有識別性，但因「X」商標圖樣整體具識別性，經主管機關即經濟部智慧財產局准許註冊後，依商標法第 35 條第 1 項規定，商標權人 A 公司就「X」商標於經註冊指定之「茶飲料、果汁、礦泉水」商品，取得商標權。「X」商標圖樣雖包含不具識別性之地名「甲」字部分，然判斷商標是否相同或近似時，仍應以「X」商標之整體商標圖樣之外觀、觀念或讀音等進行觀察。

2. 商標法第 29 條第 3 項規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」如應考人提及 A 公司不得就「甲」部分文字主張權利，屬無致商標權範圍產生疑義之虞者，依上開第 29 條第 3 項規定，無須聲明不專用，則酌予加分。

第(二)子題--A 公司請求損害賠償

1. 商標權之侵害及損害賠償相關規定：

商標法第 35 條第 1 項、第 2 項第 1 款規定：「(第 1 項)商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。(第 2 項)除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。」第 68 條第 1 款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。」(註：111 年 4 月 15 日修正商標法第 68 條第 1 項規定之理由認為，該項各款係定義侵害商標權之商標使用行為，自應適用本法總則章第五條之規定，亦即，商標之使用以行銷目的為前提。原條文之「為行銷目的」應屬重複規定，爰予刪除。但該條施行日期由行政院定之，特此註明)第 5 條第 1 項規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」

又商標法第 69 條第 3 項規定：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。」損害賠償，係為填補商標權人因侵權事實所生之損害，係採過失責任原則(有責主義)，以有故意或過失不法侵害商標權為其成立要件，故侵害商標權之行為人主觀上有故意或過失時，應負損害賠償責任。

關於商標權受侵害之損害賠償範圍，依商標法第 71 條規定：「(第 1 項)商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。(第 2 項)前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。」因此商標權人請求損害賠償時，得就該條規定損害額計算方法擇一計算其損害。

2. B 公司有商標法第 68 條第 1 款所定侵害商標權之行為：

A 公司之「X」商標圖樣雖包含不具識別性之地名「甲」字，然判斷商標是否相同或近似時，仍應以「X」商標之整體商標圖樣的外觀、觀念或讀音等進行觀察。B 公司所銷售之「X」礦泉水瓶身（包裝容器）上印有「X」圖樣（其上方有「甲」字），B 公司係為行銷其礦泉水商品之目的，而將「X」圖樣（其上方有「甲」字）用於礦泉水之包裝容器上，進而持有、販賣，足以使相關消費者認識「X」圖樣（其上方有「甲」字）為商標，屬商標之使用（商標法第 5 條第 1 項第 1、2 款規定參照）。

A 公司之「X」商標圖樣（其下方有「甲」字）與 B 公司於礦泉水瓶身上所使用之「X」圖樣（其上方有「甲」字），其商標圖樣中均有「甲」字部分，為地名之說明文字，消費者對之施以較少之注意力，故二商標圖樣均以「X」為主要識別部分，且圖樣中均有「甲」字，僅位於圖樣下方或上方之位置差異，不失其同一性，而構成相同之商標。此外，B 公司將「X」圖樣（其上方有「甲」字）用於礦泉水，與 A 公司之「X」註冊商標指定使用之商品「……礦泉水」相同，B 公司未經 A 公司之同意或授權，亦無商標法第 36 條所定不受他人商標權效力拘束之情形，故 B 公司所為係屬同法第 68 條第 1 款規定之侵害商標權行為。

3. A 公司得向 B 公司請求損害賠償 15 萬元：

因 A 公司大量宣傳推廣其所產製之「X」商標之果汁，於市場上頗受好評，B 公司同位於甲地區，銷售「X」礦泉水，於其礦泉水瓶身（包裝容器）上印有「X」圖樣（其上方有「甲」字），於同一商品，使用相同於「X」註冊商標之商標，B 公司自有侵害 A 公司就「X」商標商標權之故意，A 公司得依商標法第 69 條第 3 項規定，請求 B 公司負損害賠償責任。

就目前 A 公司所蒐集之資訊，僅知 B 公司的「X」礦泉水每瓶售價 15 元，已銷售 1 萬瓶，其數量已超過 1,500 件，故 A 公司得依商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定，以「X」礦泉水之銷售單價（即查獲侵害商標權商品之零售單價）15 元，按乘以實際出售之商品數量 1 萬瓶，以總價定賠償金額為 15 萬元。（計算式：15 元×10,000 瓶=150,000 元）。

4. 如應考人提及(1)商標法第 68 條第 2、3 款之侵害商標權態樣，及第 71 條第 1 項第 3 款規定以外之計算方式；(2)B 公司如主張商標法第 71 條第 2 項規定請求酌減損害賠償，而審酌 15 萬元之損害賠償金額有無顯不相當之情形及酌減

之必要；(3)商標法第 71 條第 1 項、第 2 項規定，本即為解決商標權人難以舉證其所受損害額所設，而將民事訴訟法第 222 條第 2 項規定法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用，則應無同法第 222 條第 2 項規定之適用機會（最高法院 109 年度台上字第 2159、2161 號民事判決參照）。以上均酌予得分或加分。

【閱卷委員的話】

第(一)子題--包含地名「甲」字之商標

本子題之重點在於「X」商標圖樣中「甲」之地理名稱是否會使相關消費者之認知產生商品說明之聯想，此涉及包含地名之商標的整體圖樣是否具備「識別性」要件與判斷。應考人多有提及識別性之判斷與商標法第 29 條相關規定，而獲得基本分數，如能詳加論述其理由者，即可獲得高分。

第(二)子題--A 公司請求損害賠償

本子題擬測驗應考人對於侵害商標權及所生損害賠償請求之判斷。應考人多有提及商標法第 68 條規定，惟多數應考人認構成第 68 條第 3 款規定，較少應考人能提及甲公司之「X」商標圖樣雖包含地名「甲」字，仍應以「X」商標之整體商標圖樣的外觀、觀念或讀音等進行觀察，更少應考人有提及 B 公司所使用之「X」圖樣（其上方有「甲」字），構成「商標之使用」，並從同一性之觀點，認定與甲公司之「X」商標圖樣係屬相同之商標。

再者，B 公司將「X」圖樣用於「礦泉水」，即與 A 公司之「X」註冊商標指定使用之商品相同，至於 A 公司實際使用「X」商標之商品、及兩公司所使用的容器材質究為玻璃或塑膠，則與商標權侵害之判斷無涉，有些應考人就此未予注意。

此外，本件損害賠償之計算，於題目已載明「就 A 公司目前所蒐集之資訊」，意指 B 公司之「X」礦泉水每瓶售價 15 元、以及銷售數量 1 萬瓶此二資訊，則依商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定計算賠償金額為 15 萬元。應考人如答以同條項第 2 款規定，同予給分。

本件涉及侵權後之請求，宜先論述構成商標權之侵害，再論損害賠償之要件，進而計算損害賠償之範圍，以顯現應考人之邏輯推理。多數應考人僅單純套用法律規定，缺少涵攝及論述，但如能表現其敘述層次者，則可獲得高分。